

1500578-61.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/05/2022

... é reincidente, pois definitivamente condenado por três roubos circunstanciados (autos n.º 0009655-98.2010.8.26.0566 - certidões de p. 95 e 289, autos n.º 0025997-19.2012.8.26.0566 - certidão de p. 97 e autos n.º 0014148-36.2001.8.26.0566 - certidões de pp. 96 e 288/289).

Além disso, ostenta condenações definitivas antigas pelos crimes de furto e roubo (autos n.º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

6ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos - SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500578-61.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500578-61.2022.8.26.0536 - Controle n.º 147/22

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réus

Kilvio Talvani Gambi e Claudinei Aparecido Brunelli

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

Vistos.

CLAUDINEI APARECIDO BRUNELLI e KILVIO TALVANI GAMBI, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas sanções previstas no artigo 155, parágrafo 4º, incisos II e IV, na forma do artigo 14, inciso II e artigo 307, todos c.c. o artigo 69, todos do Código Penal, porque no dia 14 de fevereiro de 2022, por volta de 00h30min na Rua Comendador Martins n.º 199, bairro Encruzilhada, de comum acordo, com unidade de propósitos e auxiliando-se mutuamente, mediante escalada, tentaram subtrair, para eles, uma barra de cobre, de aproximadamente dois metros, avaliada em R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e pertencente ao prédio no qual se situa o Hipermercado Roldão, só não consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade dos réus, surpreendidos e presos em situação de flagrante delito.

Consta, ainda, que no mesmo dia, mês e ano, no interior do Distrito Policial de Santos, por ocasião da lavratura de auto de prisão em flagrante, KILVIO TALVANI GAMBI e CLAUDINEI APARECIDO BRUNELLI atribuíram-se falsa identidade, afirmando que eram, respectivamente, Ercílio Barbosa Braga e Antônio Carlos Nogueira, assim agindo com o fim de obter vantagem em proveito próprio, visando eventual liberdade, uma vez que ostentam antecedentes criminais.

Diz a denúncia que, com intenção da subtração de objetos de valor, os acusados escalaram o muro e a marquise do imóvel no qual está instalado o Hipermercado

Roldão e subtraíram uma barra de cobre, de aproximadamente dois metros, bem esse pertencente ao aparelho de ar-condicionado ali instalado.

Um funcionário que trabalha no período da noite presenciou o momento em que os acusados pularam o muro, informando o ocorrido ao chefe do setor do hipermercado, o qual acionou a Polícia.

Policiais militares foram ao local e surpreenderam os réus, e embora um deles tenha tentado se ocultar na marquise do prédio, ambos acabaram detidos.

Os policiais encontraram, também, uma barra de cobre, de aproximadamente dois metros, que os réus já haviam separado, por corte, do aparelho do ar-condicionado e, um (1) arco de serra, ferramenta que utilizada para cortar a barra de cobre.

Diz, por fim, a petição inicial que os acusados foram encaminhados à Delegacia de Polícia e autuados em flagrante. Nessa ocasião, eles se atribuíram falsa identidade, afirmando que seriam Ercílio Braga e Antônio Carlos Nogueira com o objetivo de obter a liberdade. No entanto, embora tenham inicialmente logrado seu objetivo, posteriormente foi descoberta a falsidade (pp. 24/26), sendo então mantidos presos (pp. 174/175).

Recebida a denúncia (pp. 176/177), foram os réus citados pessoalmente (p. 202 e p. 204). A Defensoria Pública ofereceu a resposta de p. 210, prosseguindo-se na persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (pp. 211/212).

Na instrução, foram ouvidos o representante da vítima e duas testemunhas, procedendo-se aos interrogatórios (pp. 285/287 e 306).

Em alegações finais, por memorial, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, entendendo provados os fatos narrados na inicial. Argumentou que não é caso de aplicação do princípio da insignificância. No tocante à reprimenda, pugnou pelo aumento da pena-base diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como a consideração da agravante da reincidência em relação ao corréu Claudinei. Outrossim, pleiteou a diminuição da pena pela tentativa no patamar de 1/3 (um terço). Por fim, entendeu cabível a fixação do regime inicial aberto relativamente ao corréu Kilvio, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pretendeu, outrossim, a fixação de regime inicial semiaberto no tocante à pena a ser imposta ao corréu Claudinei, sem possibilidade de substituição por penas alternativas ou sursis (pp. 312/326).

A Defesa, por sua vez, em suas derradeiras alegações escritas, pleiteou a absolvição, alegando a insuficiência probatória relativamente ao crime de furto, e a atipicidade das condutas quanto à falsa identidade, diante da ineficácia absoluta do meio empregado. Subsidiariamente, pretendeu a fixação da pena-base no mínimo legal, a consideração da atenuante da confissão espontânea, a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência no tocante ao corréu Claudinei, o afastamento da majorante do repouso noturno e a diminuição da pena em 2/3 pela tentativa. Por fim, pleiteou a concessão do regime inicial aberto e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos em relação ao corréu Kilvio. No tocante ao corréu Claudinei, requereu a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena (pp. 341/350).

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido inicial é procedente.

A materialidade do crime de furto está demonstrada no auto de exibição, apreensão e entrega de pp. 10/11 e laudo pericial de pp. 246/252.

A materialidade dos crimes de falsa identidade está comprovada pelos boletins de ocorrência (pp. 2/4 e 24/26) e termos de interrogatório de pp. 7/8, p. 28 e p. 32, que confirmam que os acusados se identificaram como se outras pessoas fossem.

A autoria dos fatos delituosos também é certa.

Ao serem presos em flagrante delito, os acusados mantiveram-se calados (p. 28 e 32).

Em juízo, ao ser interrogado, o corréu Kilvio informou que já foi preso por roubo há dezesseis anos e cumpriu toda sua pena. Nada tem contra as testemunhas. Conhece o corréu Claudinei. Admitiu que praticou o furto juntamente com o corréu Claudinei. Afirmou que a barra de cobre já estava quebrada, motivo pelo qual subiram na marquise para pegá-la, e isso a cerca de três metros altura do solo. Ambos subiram

pelo corrimão e alcançaram o objeto pelo muro. Disse que era possível visualizar o objeto mesmo estando distante dele. Antes que descessem a Polícia os encontrou. Já conhecia o local, no qual parava para coletar papelão. Afirmou que se identificou com outro nome porque os policiais disseram que seriam agredidos caso tivessem antecedentes criminais. Forneceu o nome de seu primo, Ercilio Barbosa Braga, pessoa que não tem antecedentes criminais e reside no Rio Grande do Sul. Afirmou que descobriram sua verdadeira identidade na delegacia de polícia. Após ser questionado pelos policiais, revelou sua verdadeira identificação. Seu primo não sabe que fez uso do nome dele. Informou ser legalmente casado e residir em Santos com sua esposa. É pai de duas filhas, de 10 e 6 anos de idade, e sua esposa está grávida. A casa na qual residem é alugada. Declarou que é motorista profissional e, antes da pandemia, trabalhava como ambulante na praia. Passou a coletar recicláveis para sustentar sua família. Completou o segundo grau (gravação audiovisual, pp. 285/287).

Em juízo, ao ser interrogado, o corréu Claudinei informou que foi preso por cometer assaltos. Suas condenações são de dez anos atrás. Contou que estava recolhido na Penitenciária 1 de São Vicente e, ao obter progressão ao regime semiaberto, deixou a penitenciária e recebeu a instrução de que deveria cumprir sua pena no município de Mongaguá. Todavia, não tinha recursos para se deslocar até lá. Começou a coletar recicláveis e conheceu o corréu Kilvio nas ruas. Informou que seus irmãos residem em São Carlos/SP. Já foi amasiado e é pai de três filhos, dois deles maiores e sua filha menor conta 14 anos de idade. Seus filhos residem em São Carlos com a mãe. Narrou que estavam passando defronte ao local e viram um pedaço de cano pendurado para fora do muro. Subiram na marquise para pegá-lo e a Polícia os surpreendeu. Disse que tanto ele quanto o corréu Kilvio subiram no muro pelo corrimão para conseguirem alcançar o objeto. Os policiais chegaram enquanto ainda estavam sobre o muro. Informou que a barra de cobre estava presa em um arame, porém já estava cortada. Apenas subiram na marquise para retirá-la. Afirmou não conhecer bem a cidade e nunca havia passado naquele local. Vive em situação de rua. Informou ser mecânico de refrigeração. Permaneceu quase dois anos em liberdade e, nesse período, trabalhou como servente de pedreiro e pintor. Explicou que forneceu outra identificação porque os policiais foram agressivos e os ameaçaram. Inventou um nome naquele momento. Não conhece ninguém chamado Antônio Carlos Nogueira. Fez isso para não ser agredido pelos policiais. Não sabe se o corréu Kilvio também se identificou com nome falso. Afirmou que revelou sua identidade espontaneamente na delegacia (gravação audiovisual, pp. 285/287).

E, ao que se vê do processado, é certo que a prova aqui reunida dá sustento à condenação, pois se revela firme, segura e coerente.

M.V.F., disse que é chefe de setor do Hipermercado Roldão. Contou que o funcionário responsável pelo monitoramento noturno o informou que viu dois indivíduos escalando o muro e subindo até as instalações externas dos equipamentos de ar-condicionado. Ele também informou que acionou a Polícia. Disse que se deslocou até o estabelecimento comercial, mas não havia mais ninguém no local, de modo que se dirigiu à delegacia de polícia. Afirmou que os autores do furto possuíam uma serra e cortaram os canos de cobre do sistema de ar-condicionado. Disse que viu os réus na delegacia e realmente parecem ser as pessoas presentes na audiência virtual. Relatou que os aparelhos estão instalados a cerca de três metros de altura do solo. Houve dano no equipamento, sendo necessária a aquisição de peças novas para o conserto. Esclareceu que o funcionário que o acionou observou a ação dos réus por meio das câmeras de monitoramento. As gravações não foram entregues à autoridade policial, mas poderá fornecê-las ao juízo (gravação audiovisual, pp. 285/287).

Victor Hugo Caldeira Duarte, policial militar, relatou que foram acionados, via COPOM, porque o segurança do Hipermercado Roldão contatou a central informando que viu dois indivíduos entrando pelos fundos do estabelecimento comercial, mas não os viu sair dali. Dirigiram-se ao local e não localizaram os suspeitos. Com a chegada de outras equipes policiais encontraram os acusados na parte detrás do imóvel, em cima do suporte dos equipamentos de ar-condicionado, a cerca de três metros de altura do solo. Relatou que eles não colaboraram, pois não obedeceram a ordem para descer de onde estavam, e a equipe policial precisou usar uma escada para realizar

a prisão dos acusados. Afirmou que os réus cortaram os pedaços de cobre dos equipamentos de refrigeração. Eles possuíam uma mochila com ferramentas. Soube que um dos indivíduos forneceu o nome errado, o que foi constatado na delegacia de polícia. Eles nada falaram acerca do crime. Não mencionaram como conseguiram escalar a marquise. Disse que não conhecia nenhum dos réus. Não se recorda dos nomes dos réus ou como eles foram identificados no BOPM (gravação audiovisual, pp. 285/287).

Rafael Leão de Araújo Vale, policial militar, declarou que foram acionados, via COPOM, em razão de furto no Hipermercado Roldão. Dirigiram-se ao local e nada encontraram na parte externa. Acreditaram que o furto pudesse estar ocorrendo no interior da loja. Após uma varredura no local, encontraram os acusados na marquise do imóvel, junto aos equipamentos de ar-condicionado. Um deles desceu e o outro dificultou a prisão, obrigando-os a subir na marquise para retirá-lo de lá. Afirmou que apreenderam os canos de cobre subtraídos e uma serra. Ambos se identificaram com outros nomes. Não conhecia os réus anteriormente. Informou que a marquise situa-se a mais de três metros de altura do solo. Declarou que na confecção do BOPM constou a identificação falsa apresentada pelos réus. Esclareceu que soube da real identidade dos réus ao ser requisitado e intimado para a audiência de instrução e julgamento (gravação audiovisual, pp. 285/287).

Vê-se assim, que o contexto probatório aqui amalhado se revela coerente, harmônico e uníssono, dando ensejo ao desate condenatório.

Sob o crivo do contraditório, o representante da vítima declarou que o funcionário responsável pelo monitoramento noturno o informou que havia observado dois indivíduos escalando o muro e subindo até as instalações externas dos equipamentos de ar-condicionado, tendo acionado a Polícia Militar. Assim, compareceu ao local, porém os criminosos já havia sido levados pela equipe policial, motivo pelo qual se dirigiu à delegacia de polícia.

Os policiais militares disseram que foram informados, via rádio, sobre o furto que estava ocorrendo no Hipermercado Roldão. No local, e após realizarem buscas na parte externa do imóvel, localizaram os acusados na marquise do imóvel, na área em que estão instalados os equipamentos de refrigeração do local, com eles encontrando uma serra e a barra de cobre já retirada do sistema de ar-condicionado.

Por fim, os réus admitiram em juízo que escalaram o muro para assim acessar a marquise do imóvel, pois pretendiam subtrair o cano de cobre que, segundo eles, já estava solto, uma vez que pretendiam revendê-lo como material reciclável.

Desta forma, certo está que a confissão - manifestada sob o crivo do contraditório - encontra seguro conforto na prova aqui reunida, que indica o desate condenatório. Outrossim, certo está que se tratou de subtração tentada, que só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos réus, que se viram surpreendidos pelos policiais militares, acionados pelo funcionário da equipe de monitoramento do estabelecimento comercial.

Diga-se, ainda, que a qualificadora relativa ao concurso de pessoas é situação perfeitamente configurada, pois é de se reconhecer que os réus estavam efetivamente ajustados entre si e deram cabo à execução do crime de furto.

Inegável, pois, o auxílio e cooperação empreendidos pelos acusados, que agiram com unidade de propósitos e perpetraram a tentativa de subtração dos canos de cobre.

E, como já se decidiu:

"...O ordenamento jurídico pátrio adotou a teoria unitária ou monista, segundo a qual todos aqueles que concorreram para o crime incidem nas penas a ele cominadas, pois é tido como coautor todo o agente que desempenha tarefa necessária ao êxito global da infração. Para a caracterização da coautoria no concurso de pessoas é necessário somente a colaboração do agente para o deslinde da prática delituosa, não se exigindo que todos os partícipes tenham consumado atos típicos de execução..." (TJSP; Apelação Criminal 1503167-16.2018.8.26.0229; Rel. Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 11/06/2020).

Também não se poderia desconsiderar a qualificadora prevista no inciso II do parágrafo 4º do artigo 155 do Código Penal, relativamente à escalada, que foi adequadamente comprovada.

O laudo pericial apontou que "... os vestígio aparentes de aspecto recente

identificados e possivelmente relacionáveis com o objeto da requisição, consistia em vestígios de escalada deixados em uma parede de ao menos três metros de altura" (pp. 246/252).

Certo, assim, que os acusados se valeram de especial destreza e meio não comum para alcançarem a marquise do estabelecimento onde estavam instalados os equipamentos de ar-condicionado, marquise essa localizada a razoável altura (cerca de 3 metros do solo), tendo eles se utilizado de corrimão para acessarem o muro, sendo forçoso reconhecer que demonstrada se tem a qualificadora prevista no inciso II do parágrafo 4º do artigo 155 do Código Penal.

Além disso, é de se reconhecer que caracterizada e comprovada está a ocorrência da causa de aumento de pena do repouso noturno, que está implicitamente descrita na denúncia, em razão de o furto ter ocorrido durante a madrugada (00h30min), período em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da diminuição da vigilância exercida sobre a res.

Note-se, outrossim, que é de se reconhecer a referida causa de aumento de pena ainda que o crime tenha ocorrido em estabelecimento comercial, justamente em razão da menor vigilância do bem durante o período do repouso noturno. Essa, certamente, a mens legis.

E, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. REPOUSO NOTURNO. MAJORANTE. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. 1. Consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, a causa de aumento do art. 155, § 1º, do CP, é aplicável tanto para o furto simples como para o qualificado e independe de o local do fato encontrar-se habitado ou não durante a execução do crime. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento." (AgRg no REsp 1726761/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 03/12/2019).

Afora isso, destaque-se que não é caso de se afastar a incidência da majorante do repouso noturno sob o argumento de que a existência de câmeras de segurança excluiria a menor vigilância sobre a res.

A existência de sistema de vigilância humana ou eletrônica não impede, por si só, a consumação delitiva e, de igual modo, não exclui a vulnerabilidade da coisa durante o repouso noturno. Se muito, permite imediata percepção da conduta delituosa e possível ação do proprietário da coisa visando impedir a consumação da infração penal, sem que se tenha exclusão da voluntariedade da conduta dos agentes que atacam patrimônio alheio.

Nesse sentido, cabe o julgado:

"...A existência de monitoramento eletrônico e segurança patrimonial no local dos fatos não afasta a incidência da causa de aumento de pena do repouso noturno, circunstância esta que possui caráter objetivo" (TJ-MG - APR: 10317190087161001 Itabira, Relator: Glauco Fernandes, Data de Julgamento: 01/07/2020, Câmaras Criminais / 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/07/2020).

Ressalte-se, pois, que é necessário dar aos fatos a adequada definição jurídica, procedendo-se à emendatio libelli, uma vez que os fatos corretamente narrados na denúncia imputam aos réus a prática do furto qualificado praticado durante o repouso noturno.

Com efeito, ao que narra a petição inicial, o crime ocorreu por volta de 0h30min, ou seja, no início da madrugada

Desta forma, cabível a emendatio libelli, prevista no artigo 383 do Código de Processo Penal, pois sem modificar a descrição dos fatos narrados na petição inicial, é de se dar nova e adequada definição jurídica à conduta dos réus, tipificando-a no artigo 155, parágrafos 1º e 4º, incisos II e IV, do Código Penal. No tocante ao delito de falsa identidade, a procedência do pedido também se impõe. Por certo, plenamente demonstrado que os acusados declinaram falsas identidades em razão da prisão em flagrante delito, fato este estampado no boletim de ocorrência e em seus interrogatórios na fase inquisitorial, fornecendo os dados de identificação de outras pessoas (pp. 24/26 e 7/8).

Não há como falar que com o meio empregado pelos agentes era impossível ludibriarem os policiais, pois "a identificação criminal, consistente na coleta das impressões

digitais (material dactiloscópico) não torna o meio absolutamente ineficaz" (TJSP; Apelação Criminal 2000114-29.2012.8.26.0439; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 24/02/2015).

O corréu Kilvio declinou o nome de Ercílio Barbosa Braga e o corréu Claudinei se identificou como Antônio Carlos Nogueira à autoridade policial, agindo ambos com a finalidade de esconder seus antecedentes criminais, destacando-se que, em relação a Claudinei, é certo que também pretendia ocultar sua situação de foragido da justiça, de forma que os policiais civis somente souberam seus verdadeiros nomes e demais dados de qualificação pessoal após pesquisa realizada junto ao instituto de identificação - IIRGD.

Destaque-se, neste ponto, que os documentos aqui mencionados foram elaborados com base nas informações fornecidas pelos réus, que não somente se identificaram com o nome de um familiar ou de um desconhecido, como forneceram os dados de filiação e data de nascimento deles.

Aliás, os próprios acusados admitiram a prática do crime e, ao que se viu, quando presos em flagrante delito se identificaram com nome e dados de qualificação de terceiros dizendo que temiam a represália dos policiais militares por ostentarem maus antecedentes.

Outrossim, de se ressaltar que, como se verificou na audiência de instrução e julgamento, os policiais militares sequer souberam que foi apurada a verdadeira identidade deles, já que lavraram o BOPM com anotação de dados falsos que os réus lhes forneceram por ocasião da detenção (pp. 327/337).

Note-se, ademais, que não há como absolver os acusados por não ter havido qualquer vantagem ou dano, pois "consuma-se o crime com o ato de atribuir-se ou atribuir a outrem falsa identidade. Trata-se de crime formal, de maneira que o delito se perfaz independentemente da obtenção da vantagem ou da produção de dano a terceiro" (Capez, Fernando. Curso de direito penal. v. 3. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 427).

E, por certo, não se cogita de conduta atípica, pois é certo que não poderia, em nome de possível autodefesa, omitir sua verdadeira identidade e, visando ludibriar a autoridade policial, atribuir-se falsa identificação.

Não há como entender lícita a conduta daquele que, em nome de suposta autodefesa, omite a real identidade, a pretexto de não ser responsabilizado na esfera criminal. Em casos como o presente, esta é a orientação do Supremo Tribunal Federal:

"EMENTA CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA. ARTIGO 5º, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA. O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP). O tema possui densidade constitucional e extrapola os limites subjetivos das partes." (RE 640139 RG / DF - Distrito Federal, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Julgamento: 22/09/2011).

Frise-se, por oportuno, o entendimento sedimentado na Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça: "A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa".

Logo, comprovado que os corréus Kilvio e Claudinei se atribuíram falsa identidade, o fato é típico, configurando-se, pois, o crime previsto no artigo 307 do Código Penal.

Procede, portanto, a ação penal.

Passo à individualização da pena.

I - Claudinei A parecido Brunelli

Inicialmente, ressalto que há duas qualificadoras comprovadas - concurso de agentes e escalada - sendo utilizada a primeira para qualificar o crime e migrada a segunda para as circunstâncias judiciais; do contrário, uma das qualificadoras seria desprezada e não é correto punir um furto duplamente qualificado com a mesma pena de um furto qualificado.

O acusado é reincidente, pois definitivamente condenado por três roubos circunstanciados (autos n.º 0009655-98.2010.8.26.0566 – certidões de p. 95 e 289, autos n.º 0025997-19.2012.8.26.0566 – certidão de p. 97 e autos n.º 0014148-36.2001.8.26.0566 – certidões de pp. 96 e 288/289).

Além disso, ostenta condenações definitivas antigas pelos crimes de furto e roubo (autos n.º 0010274-19.1996.8.26.0566 – certidão de p. 95 e pp. 103 e 105, autos n.º 0015674-99.1999.8.26.0566 – certidões de pp. 96 e 288), as quais, ainda que não sirvam para configurar a agravante da reincidência, ante o decurso do quinquênio legal, maculam sua vida pregressa e deixa claro que a situação pessoal do acusado difere daquela de pessoa sem nenhum envolvimento em prática criminosa.

Nestes termos, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, nos autos do RE 593.818, fixou a tese de que: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", decidindo que condenações criminais extintas há mais de cinco anos podem ser consideradas como maus antecedentes para a fixação da pena-base em novo processo criminal.

Ademais, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"... No Superior Tribunal de Justiça, há o entendimento de que o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes...". (AgRg no HC 509.034/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020).

De outro lado, o réu admitiu a prática das condutas criminosas.

Assim, em relação ao crime de furto, levando em conta os critérios elencados no artigo 59 do Código Penal, em especial em razão dos maus antecedentes e das circunstâncias desfavoráveis do crime, pois o furto foi praticado mediante escalada, aumento a pena-base em 1/3 (um terço), fixando-a em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Comprovada a reincidência específica, representada por 3 (três) condenações definitivas, todas elas por roubo majorado, o que não poderia ser desprezado, agravo a pena em 1/2 (metade), fixando-a em 4 (quatro) anos de reclusão, e 19 (dezenove) dias-multa.

Consoante estabelece o artigo 67 do Código Penal, no concurso de agravantes e atenuantes, preponderam as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

Não se olvida da existência de julgados recentes, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, adotando o entendimento de que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea seriam circunstâncias igualmente preponderantes.

No entanto, de acordo com o entendimento tradicional, e ainda, majoritário, inclusive adotado pelo Supremo Tribunal Federal, a reincidência é circunstância subjetiva de maior prevalência.

A respeito decidiu o Supremo Tribunal Federal:

"... REINCIDÊNCIA – PREPONDERÂNCIA. A agravante reincidência prevalece sobre a confissão – artigo 67 do Código Penal. (RHC 141519, Relator(a): Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 31/08/2020, processo eletrônico dje-223 divulg 08-09-2020 public 09-09-2020).

Logo, sendo a reincidência circunstância preponderante em relação à atenuante da confissão, inviável a compensação entre elas.

Outrossim, cabe observar que o réu ostenta maus antecedentes por crimes patrimoniais (roubo e furto), o que revela não ser suficiente a integral compensação entre as circunstâncias.

Afora isso, verifica-se a existência de três condenações anteriores em desfavor do acusado, todas aptas a configurar a reincidência, o que desautoriza a concessão da pleiteada compensação.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"... A jurisprudência desta Corte superior é no sentido de que, se tratando de réu

multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade..." (HC 531.187/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019 )..." (AgRg no HC 663.271/SC, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

"...Tratando-se de réu multirreincidente, cabível a compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, tal como ocorre na espécie, em que o paciente ostenta três condenações transitadas em julgado, tendo sido utilizada uma para negativar os antecedentes e duas para reconhecer a reincidência..." (AgRg no HC n. 626.637/SC, relator Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 8/2/2021)

Assim, presente a atenuante da confissão, atenuo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, verificada a causa de aumento de pena prevista no parágrafo 1º do artigo 155 do Código Penal, já que se tratou de subtração praticada durante o repouso noturno, aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa.

Tratando-se de crime tentado, e à vista do iter criminis percorrido pelos agentes, que efetivamente cerraram o cano de cobre, arrancando-o do equipamento de ar-condicionado, e foram surpreendidos quando ainda estavam sobre a marquise, só não consumando o delito devido a intervenção da Polícia Militar, diminuo a pena em 1/2 (metade).

Assim, fixo a pena em 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Em relação ao crime de falsa identidade, levando em conta os critérios elencados no artigo 59 do Código Penal, por considerar os comprovados maus antecedentes, como já se frisou, aumento a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Comprovada a reincidência, representada por 3 (três) condenações definitivas por roubo majorado, agravo a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Consoante acima referido, sendo a reincidência circunstância preponderante em relação à atenuante da confissão, inviável a compensação entre elas.

Outrossim, cabe observar que o corréu Claudinei ostenta maus antecedentes e verifica-se a existência de três condenações anteriores em desfavor do acusado, todas aptas a configurar a reincidência, o que desautoriza a concessão da pleiteada compensação.

Assim, presente a atenuante da confissão, atenuo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 3 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção.

Deixo de aplicar a pena pecuniária por entender que, na situação aqui analisada, ela não é suficiente e nem adequada à reprovação da conduta criminosa comprovada. Como se viu, há que se entender que os crimes de furto e falsa identidade foram praticados em concurso material.

Desta forma, e nos termos do disposto no artigo 69 do Código Penal, somam-se as penas impostas aos delitos descritos na denúncia, somatória essa que alcança 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 3 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, e 10 (dez) dias-multa

Apesar do quantum de pena aplicada, ante a reconhecida reincidência representada por 3 (três) condenações definitivas por crimes contra o patrimônio, e evidenciadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias do crime e maus antecedentes), iniciará o réu o cumprimento da pena de reclusão em regime fechado, e a pena de detenção em regime semiaberto.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou concessão de sursis, face a reincidência do acusado e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como porque tal substituição não seria recomendável e nem suficiente para reprovação de tal conduta delituosa.

Não havendo informações concretas acerca da situação econômica do acusado, fixo o



dia-multa no valor unitário mínimo legal.

II – Kilvio Talvani Gambi

Inicialmente, ressalto que há duas qualificadoras comprovadas – concurso de agentes e escalada – sendo utilizada a primeira para qualificar o crime e migrada a segunda para as circunstâncias judiciais; do contrário, uma das qualificadoras seria desprezada e não é correto punir um furto duplamente qualificado com a mesma pena de um furto qualificado.

O acusado é tecnicamente primário.

Todavia, possui condenação definitiva antiga pela prática de roubo circunstanciado e porte ilegal de arma de fogo (autos n.º 0005624-96.2000.8.26.0562 - certidão de p. 100 e FA pp. 124 e 128) a qual, ainda que não sirva para configurar a agravante da reincidência, ante o decurso do quinquênio legal, macula sua vida pregressa e deixa claro que a situação pessoal do acusado difere daquela de pessoa sem nenhum envolvimento em prática criminosa.

Nestes termos, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, nos autos do RE 593.818, fixou a tese de que: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", decidindo que condenações criminais extintas há mais de cinco anos podem ser consideradas como maus antecedentes para a fixação da pena-base em novo processo criminal.

Ademais, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"... No Superior Tribunal de Justiça, há o entendimento de que o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes...". (AgRg no HC 509.034/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020).

Outrossim, se vê processado pelos crimes de furto e receptação (autos n.º 1511268-08.2021.8.26.0562 – certidão de p. 100), mas tal apontamento não será aqui considerado, nos termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Por outro lado, o acusado é confesso quanto a prática dos delitos aqui imputados. Assim, em relação ao crime de furto, levando em conta os critérios elencados no artigo 59 do Código Penal, em especial em razão dos maus antecedentes e das circunstâncias desfavoráveis do crime, pois o furto foi praticado mediante escalada, aumento a pena-base em 1/3 (um terço), fixando-a em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Presente a atenuante da confissão, atenuo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase, verificada a causa de aumento de pena prevista no parágrafo 1º do artigo 155 do Código Penal, já que se tratou de subtração praticada durante o repouso noturno, aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Tratando-se de crime tentado, e à vista do iter criminis percorrido pelos agentes, que efetivamente cerraram o cano de cobre, arrancando-o do equipamento de ar-condicionado, e foram surpreendidos quando ainda estavam sobre a marquise, só não consumando o delito devido a intervenção da Polícia Militar, diminuo a pena em 1/2 (metade).

Assim, fixo a pena em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e 6 (seis) dias-multa.

Em relação ao crime de falsa identidade, levando em conta os critérios elencados no artigo 59 do Código Penal, por considerar os comprovados maus antecedentes, como já se frisou, aumento a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Assim, presente a atenuante da confissão espontânea, diminuo a pena ao mínimo legal, fixando-a em 3 (três) meses de detenção.

Deixo de aplicar a pena pecuniária por entender que, na situação aqui analisada, ela não é suficiente e nem adequada à reprovação da conduta criminosa comprovada.

Como se viu, há que se entender que os crimes de furto e falsa identidade foram praticados em concurso material.

Desta forma, e nos termos do disposto no artigo 69 do Código Penal, somam-se as penas impostas aos delitos descritos na denúncia, somatória essa que alcança 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) de reclusão, 3 (três) meses de detenção, e 6 (seis) dias-multa.

Ante o quantum de pena aplicada, o réu faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, uma vez que, no caso sub judice, tal medida parece ser socialmente recomendável, e a substituição de uma delas por pena de multa não se mostra adequada à reprovação da conduta criminosa aqui apurada. É necessário gizar que destaque negativo quanto às circunstâncias do crime e maus antecedentes, por si só, não obsta a substituição, pois a análise conjunta de todas as outras circunstâncias do inciso II do artigo referido indicam como suficiente a repressão e prevenção do crime.

Assim, substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços e prestação pecuniária, na forma do previsto nos artigos 45 e 46 do Código Penal. Fica o réu condenado ao cumprimento de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias de prestação de serviços à entidade assistencial, hospital, escola, orfanato ou outro estabelecimento congênere, inseridos em programas comunitários ou estatais, entidade esta que será indicada pelo Juízo da Execução.

Fica condenado, também, ao pagamento de prestação pecuniária estipulada em 1 (um) salário mínimo, a ser pago em dinheiro e em favor de entidade pública ou privada de destinação social a ser indicada pelo Juízo da Execução, na forma do previsto no parágrafo 1º do artigo 45 e 46 do Código Penal.

Por ser primário, em caso de conversão de qualquer das penas restritivas de direitos ora imposta, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Não havendo informações a respeito da situação econômica do acusado, fixo o dia-multa no mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para:

a) condenar CLAUDINEI APARECIDO BRUNELLI, qualificado nos autos, à pena de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado, 3 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, a serem cumpridos inicialmente em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, por incurso nas sanções previstas no artigo 155, parágrafos 1º e 4º, incisos II e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, e artigo 307, todos c.c. o artigo 69, todos do Código Penal;

b) condenar KILVIO TALVANI GAMBI, qualificado nos autos, à pena de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias de prestação de serviços à entidade assistencial, hospitalar, escola, orfanato ou outro estabelecimento congênere, inserido em programas comunitários ou estatais, entidade esta que será indicada pelo Juízo da Execução; prestação pecuniária, fixada em 1 (um) salário mínimo devido a entidade pública ou privada de destinação social, que também será indicada pelo Juízo da Execução, penas essas que, em caso de conversão, deverão ser cumpridas inicialmente em regime aberto, bem como 6 (seis) dias-multa, calculados ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, por incurso nas sanções previstas no artigo 155, parágrafos 1º e 4º, incisos II e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, e artigo 307, todos c.c. o artigo 69, todos do Código Penal.

Nos termos do disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, arcarão os réus com custas processuais correspondentes a 100 (cem) UFESP'S, calculadas ao valor vigente à época do pagamento.

Entretanto, e tratando-se de réus a quem se nomeou Defensor Público, é de se presumir que não tenham condições de arcar com o pagamento de custas, razão pela qual há de se observar o previsto no artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

O acusado Claudinei viu convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva. É certo que o fato aqui apurado desassossega a sociedade, compromete a paz social e

desequilibra a ordem pública.

Assim, a prisão por sentença condenatória recorrível se revela necessária, seja para assegurar a efetiva aplicação da lei penal, bem como para resguardo da ordem e paz públicas.

Lembre-se que o réu é multireincidente em crimes contra o patrimônio, possuindo condenações definitivas por crimes graves de roubo majorado.

Ademais, foi condenado pelo crime de falsa identidade, o que reforça que a sua prisão por sentença condenatória recorrível se mostra necessária para assegurar a aplicação da lei penal.

Por final, necessário registrar que as medidas elencadas nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal não se mostram adequadas para acautelar o procedimento, agora julgado nesta Instância, sendo forçoso reconhecer que, em liberdade, o acusado poderá por em risco a aplicação da lei penal, pois condenado a cumprir pena em gravoso regime, destacando-se que constava ser foragido do sistema prisional.

Assim, recomende-se o corréu Claudinei Aparecido Brunelli na prisão em que se encontra.

Anotem-se as condenações definitivas no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça.

P.I.C.

Santos, 30 de maio de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA